

1500818-07.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... nada. Afirmou que ele foi preso por tráfico de drogas, tendo sido 'pego numa escuta telefônica', tendo ligação com o PCC.

O acusado David Faria dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do tráfico de drogas. Disse que, quando foi preso, não estava se relacionando com a ré. Afirmou que, posteriormente, voltou a manter relações com ela. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500818-07.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500818-07.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199833/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 19218597 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 4094/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2199833 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BIANCA DE OLIVEIRA BARBOZA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados Bianca de Oliveira Barboza da Silva e David Faria dos Santos, já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, quanto ao acusado, de forma tentada.

Segundo a denúncia, a acusada, no dia 24 de julho de 2021, às 09:30 horas, nas dependências do CDP de Bauru, situado na Rodovia SP 294, km 394, Distrito Industrial III, na cidade de Bauru/SP, trazia consigo, para o tráfico ilícito, 01 porção de 51,09g (cinquenta e um gramas e nove centigramas) de maconha, substância

entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, segundo a exordial, o acusado, no dia 24 de julho de 2021, às 09h30, nas dependências do CDP de Bauru-SP, situado na Rodovia SP 294, 394, Distrito Industria III, na cidade de Bauru-SP, tentou adquirir, para o tráfico ilícito, 01 porção de 51,09g (cinquenta e um gramas e nove centigramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mas não conseguiu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 16/20) e laudo definitivo (fls. 98/101).

Pelo crime, foi a acusada preso em flagrante.

Durante a análise formal do ato (fls. 71/75), foi concedida a liberdade provisória à acusada, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pela decisão de fls. 94/96, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados.

Os réus foram, formalmente, citados (fls. 134 e 136), tendo ofertado respostas à acusação (fls. 118/122 e 125/131).

Na decisão de fls. 150/152, houve a manutenção do recebimento da denúncia.

Durante a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento de fls. 257/259 a D. Defesa da acusada desistiu da oitiva da testemunha Aline, pleito homologado. Ainda, no mesmo ato processual, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e foram interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 264/272 pugnando, em suma, pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da exordial, com exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06, a constatação da agravante do "estado pandêmico" e a reincidência específica apenas no que tange ao acusado, a constatação da majorante prevista no art. 40, III da Lei nº 11.343/06, o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando-se o regime inicial fechado.

Já a D. Defesa Constituída do acusado David às fls. 275/279 pleiteou, em síntese, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Por fim, o C. Mandatário da acusada Bianca às fls. 309/311 requereu, uma vez mais, a concessão do ANPP e, no mérito, pela aplicação da benesse insculpida no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, com a substituição da privativa por restritivas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Quanto à possibilidade de ANPP avençada pela D. Defesa da acusada Bianca, pontua-se que a impossibilidade foi delimitada pela decisão de fls. 290/297, sem que houvesse, agora, qualquer alteração.

Portanto, o indeferimento fica mantido, forte na motivação "per relationem".

No mérito, a pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito de tráfico está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 10/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), laudo de constatação preliminar (fls. 16/20) e laudo definitivo (fls. 98/101).

A autoria, de outra banda, induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

O agente penitenciário Carlos Alberto Bibó, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), em resumo, disse que foi chamado para fazer o transporte da acusada, não tendo acesso aos autos. Afirmou que soube que, quando a ré tentava entrar nas dependências do CDP, o scanner detectou um objeto estranho. Informou que ela foi levada até uma sala onde, na presença de policiais femininas, ela teria mostrado que trazia no bojo de seu sutiã algumas porções de maconha.

A agente penitenciária Elaine de Fátima Crepaldi Graebin, sob o devido processo legal (mídia SAJ), disse que a acusada passou pelo scanner, momento em que foi detectada a presença de algo estranho. Afirmou que levou a acusada até uma sala reservada, onde ela mesmo levantou a blusa e mostrou um invólucro enrolado em plástico com substância entorpecente que estava escondido em seu sutiã. Informou

que ela contou que não sabia que se tratava de droga. Esclareceu que uma pessoa desconhecida, do lado de fora da penitenciária, lhe pediu para entrar com aquele objeto.

Aqui, uma ressalva.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais, não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são cancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

As testemunhas de defesa Everton Augusto, Simone dos Santos e Cristiane de Oliveira, em juízo (mídia SAJ), declinaram não presenciaram os fatos, e, por isso, são consideradas abonatórias.

A acusada Bianca de Oliveira Barboza da Silva, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), em síntese, confessou a prática delitativa. Disse que levou a droga para o acusado para agradá-lo, mas ele não sabia de nada. Afirmou que ele foi preso por tráfico de drogas, tendo sido 'pego numa escuta telefônica', tendo ligação com o PCC.

O acusado David Faria dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, negou a prática do tráfico de drogas. Disse que, quando foi preso, não estava se relacionando com a ré. Afirmou que, posteriormente, voltou a manter relações com ela. Durante uma visita, ela foi 'pega com droga'. Informou que não sabia da existência daquele entorpecente. Esclareceu que foi usuário de maconha, mas não mais a consome.

Pela prova colhida, é de rigor a condenação pelo delito de tráfico de drogas, de ambos os acusados.

Com efeito, os policiais penais surpreenderam a acusada portando 'algo estranho'. Imediatamente, ela elucidou à agente feminina que era droga (maconha), escondida no sutiã.

Aqui um recorte.

Na fase policial Bianca elucidou: (...) Da mesma forma, disse ter uma filha de dois anos e meio, aos seus cuidados. Em relação aos fatos, afirma que foi visitar seu marido, DEIVID FARIA DOS SANTOS, pai de seu filha, o qual está preso no CDP de

Bauru. Que no momento em que estava na fila, uma mulher desconhecida se aproximou e pediu para que entrasse com um volume de plástico, dizendo que era papel enrolado e que deveria ser entregue ao seu marido. Depois que foi abordada no escaner disse aos agentes que não sabia do que se tratava e posteriormente lhe falaram que era maconha. Que não sofreu nenhum tipo de ameaça da tal moça que lhe entregou o volume. Que não tinha conhecimento de que era maconha. Que seu marido era usuário de maconha e não sabe o delito que seu marido cometeu. Que ficou com medo e por tal motivo acabou aceitando o volume para entregar no interior da unidade prisional, temendo por sua integridade e de seus familiares.

A versão não convence.

Se o acusado 'tem ligação com o PCC', não é razoável, dado tal 'grupo', que a acusada tenha tido medo 'de alguém que lhe ofereceu algo'.

Depois, também não é razoável que, primária, e sabendo que o delito anterior do amásio foi o mesmo, tenha entrado com a droga, sem que ele fosse atualmente usuário, apenas para 'agradá-lo'.

De se citar, ainda, que a droga foi apreendida em formato de "linguiça", ou seja, não usualmente pronta para utilização (fls. 17).

Sob outro vértice, pelo que se tem dos autos, o acusado também cometeu o delito, portanto.

Com efeito, ele não "tentou adquirir" como descrito na inicial, seja por ausência de negociação ou mesmo pela inexistência de tentativa de pagamento.

Ocorreu, diversamente, é a materialização da teoria do domínio do fato.

No ponto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOMÍNIO DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tendo o réu conhecimento prévio e pleno domínio da conduta da corré, que tentou ingressar com droga em estabelecimento prisional, deve ser condenado pelo delito de tráfico de drogas.

2. É desnecessária, para a configuração do delito de tráfico, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 483235 / BA, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 25/09/2018)

Na mesma linha, trechos do substancial voto da relatora Exma. Des. Ivana David da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Bandeirante, no âmbito do feito nº 1500387-74.2019.8.26.0583, julgado em 05/04/2022: (...) Fato é que, conforme bem obtemperado pelo douto sentenciante, "dado o relacionamento íntimo mantido entre o réu sentenciado e sua companheira, não há nos autos elementos que convençam que terceiro diverso seria o destinatário da droga transportada pela ré visitante, o que conduz a insubsistência do álibi e necessidade de responsabilização penal do casal de réus." (fls. 425) (...) E, diante da extensiva tipificação penal, não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "trazer consigo" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla. (...)

Deste modo, no aspecto, resta operada a emendatio libelli.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelo delito previsto no art. 33 "caput" combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, em coautoria.

Passo à fixação da pena.

Ré Bianca de Oliveira Barboza da Silva

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade da acusada.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 235).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A coletividade (saúde pública) foi maculada nos estritos termos do tipo legal.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do

tipo.

Por isso, a pena-base permanece no mínimo previsto, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, quanto à agravante do “estado pandêmico” deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que ‘não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19’.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Prova suficiente à condenação – Tipicidade formal e material da conduta presentes – Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública – Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito – Não reconhecimento da participação de menor importância – Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor – Concessão de regime inicial aberto – Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Ainda na mesma fase, a confissão não tem o condão em atenuar a reprimenda aquém do mínimo, forte na Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, aplicável a majorante prevista no art. 40, III da Lei Antitóxicos.

Por isso, a pena é aumentada em 1/6, atingindo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias.

Excepcionalmente, no tocante à acusada, é aplicável o redutor previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, a natureza (maconha) e ausentes de outros apontamentos denotam que ela era “traficante de primeira viagem”.

Entretanto, a quantidade (51,09g) e a forma de apreensão, formato similar a uma “linguiça”, denotam que a redução não pode ser total.

No aspecto:

“(…)No tocante às reprimendas impostas, a r. sentença demanda reparo.

Inicialmente, verifica-se que, sopesadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Tóxicos, em especial a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, a pena base foi fixada em 07 anos de reclusão mais 700 diárias. Contudo, a qualidade e quantidade de drogas devem ser consideradas na derradeira etapa, no momento da aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 que, no caso, é de rigor. Destarte, a pena base fica estabelecida no patamar mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão mais 500 diárias, que permanece inalterada na segunda etapa, diante da ausência de circunstâncias atenuante ou agravante. Na derradeira etapa do sistema trifásico, incidindo a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Tóxicos, as sanções sofrem acréscimo de 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Em seguida, mister aplicar-se a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, em favor do réu, posto inexistir prova que este se dedique, comprovadamente, a atividades ilícitas nem integre organização criminosa (até porque afastada a imputação do crime de associação).” [grifo nosso] (TJ-SP - APL: 0014716-31.2014.8.26.0361, Relator: Guilherme G. Strenger, Data de Julgamento: 02/03/2016, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2016)

Portanto, a reprimenda é reduzida em metade, atingindo, em definitivo, 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Réu David Faria dos Santos

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade da acusada.

O réu possui antecedentes criminais (fls. 232/234).

É o feito nº 1025786-49.2019, anterior ao presente, com trânsito em julgado posterior.

Nesse sentido:

[...] 2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, diz respeito ao histórico do acusado e pode caracterizar Maus Antecedentes. [...] 5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para reduzir a pena-base, afastar a reincidência e redimensionar a pena final da paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa. (STJ, HC 145.443/DF, Rogério Schietti Cruz, 6ª T., DJe 10/11/2014) Também:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. (Precedentes).

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC nº 424759-SP, relator ministro Felix Fischer, julgado em 13/03/2018).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

A coletividade (saúde pública) foi maculada nos estritos termos do tipo legal.

As circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena-base deve sofrer exasperação em 1/6, perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, como dito, por ausência de nexo de causalidade, não aplicável a agravante do "estado pandêmico".

Ainda na segunda fase, o acusado é reincidente específico (feito nº 0000403-94.2016).

No ponto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR PELO MESMO DELITO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta.

3. Na hipótese, sendo específica a reincidência do agente, não há ilegalidade no aumento da pena na fração de 1/3, a autorizar excepcionalmente a intervenção desta Corte.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 380574 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/06/2017)

Por isso, a pena é agravada em 1/3, atingindo 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) diárias.

Na derradeira, aplicável a majorante prevista no art. 40, III da Lei Antitóxicos.

Por isso, a pena é aumentada em 1/6, atingindo 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 906 (novecentos e seis) dias-multa.

Por fim, inaplicável a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes.

Nem se fale que haveria bis in idem na utilização da reincidência na segunda fase e na derradeira, por que o instituto é utilizado de maneira diversa.

Na intermediária, a reincidência é fator para agravar a pena, já que sempre deve agravar a reprimenda, nos estritos termos do art. 61 "caput" do Código Penal, e, ressalvadas as hipóteses legais.

Já na última fase é pressuposto para negar o redutor previsto no art. 33, §4º da lei 11343/06, salientando-se que os requisitos lá plasmados são cumulativos.

A variação da diminuição na minorante é cotejada com fatores diversos, tais como quantidade e natureza da droga (quando não utilizados na primeira fase), as circunstâncias da ocorrência, a personalidade do acusado, ou seja, de modo geral, o próprio art. 42 da lei 11343/06.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte estadual, na terceira fase da dosimetria, sopesou não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que os acusados se dedicariam a atividades delituosas, especialmente ao narcotráfico, motivo pelo qual não há falar em bis in idem.

2. A simples reincidência dos réus já é elemento suficiente para, por si só, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes.

3. Se ainda não houver decorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior é geradora de reincidência, independentemente de ela ser ou não pela prática do mesmo delito.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1382648 / SP, por unanimidade, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 18/06/2019)

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica dos acusados.

Fixo o regime inicial aberto para a acusada Bianca, nos termos do art. 33, §2º, "c" e §3º do Código Penal.

No que tange ao acusado David o regime é o inicial fechado.

Ocorre que a reincidência e os maus antecedentes, além do montante da pena tornam o mais gravoso único a reprimir e ressocializar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser

apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.

3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 695249 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/10/2021)

As penas restritivas não podem ser acessadas.

Quanto à acusada, pela insuficiência.

Ocorre que ela portava droga, pronta para a venda, e entrava com ela em um presídio.

Além disso, o ex-companheiro é membro de conhecido grupo criminoso (PCC), sendo que tal entorpecente, serviria, ainda mais, para fomentar as práticas delitivas.

No que tange ao acusado, os maus antecedentes, reincidência específica e montante da pena impedem a benesse.

Portanto, incabíveis as alternativas, nos termos do art. 44, II e III do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL e, desta feita: CONDENO o acusado David Faria dos Santos, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06;

CONDENO a acusada Bianca de Oliveira Barboza da Silva, qualificada nos autos, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, com diárias no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06.

Os acusados responderam ao processo em liberdade, e nesta condição poderão recorrer.

Quanto aos entorpecentes apreendidos, autorizo a destruição.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeçam-se incontinenti guias definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os acusados a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhes a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA